

1500206-15.2022.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... das anotações, que na agenda, fazem referência ao tráfico, junto aos entorpecentes - fls. 128/130), transparecem a finalidade comercial do tipo penal.

Observe-se que os entorpecentes apreendidos já se encontravam em pequenas porções, adrede preparados para venda, que a abordagem fora realizada em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e realizada a pós ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500206-15.2022.8.26.0633 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 09/10/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500206-15.2022.8.26.0633

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIELBERGUES FERREIRA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS.

DANIELBERGUES FERREIRA ALVES, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos delituosos narrados na introital de fls. 01/02, a saber:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de junho de 2022, por volta das 20h, na rua Antônio Carlos Prado, 98, Jardim Coronel, neste município e comarca de Itanhaém, DANIELBERGUES FERREIRA ALVES, qualificado à fl. 06, trazia consigo 29 tiras de Cannabis sativa L, 93 pedras de crack, 26 porções de cocaína, 03 frascos contendo lançaperfume, 72 potes contendo skunk e 105 envelopes plásticos contendo Cannabis sativa L, drogas destinadas à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, o denunciado veio do município de São Paulo trazendo consigo os entorpecentes acima descritos,

dentro de uma sacola plástica, visando a abastecer um conhecido ponto de venda localizado no bairro Jardim Coronel, Itanhaém. Ocorre que, seguindo prévias informações, policiais militares rumaram para o local, oportunidade em que o denunciado tentou fugir correndo, ingressando no banheiro de um bar, sendo preso em flagrante ainda em poder da sacola contendo as drogas, seguindo-se a apreensão de anotações típicas de tráfico e de R\$ 152,00, valor auferido com a venda de entorpecentes.”

Acompanhou a denúncia o auto de prisão em flagrante, no qual, estando em termos, foram juntados, dentre outros documentos, termos de declarações, boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de constatação prévia de entorpecente (fls. 25), auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), nota de culpa (fl. 56), laudo toxicológico (fls. 124/127, 167/169 e 206/208) e o relatório lavrado pela Polícia Judiciária (fls. 128/130).

Por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com esteio no art. 312 do Código de Processo Penal, por entendê-la necessária à garantia da ordem pública (fls. 73/76). Mandado de prisão expedido (fls. 79/80) e devidamente cumprido (fls. 92/93).

Às fls. 140/141, apontou-se que o presente feito seguiria o rito comum ordinário, previsto no art. 396 e ss. do CPP, porquanto mais amplo, inexistindo qualquer prejuízo à douta Defesa. Na ocasião, porquanto preenchidos os requisitos legais, foi recebida a denúncia e determinou-se a citação do inculcado. Citado (fl. 225), o réu apresentou resposta à acusação por intermédio de defensora dativa (fls. 232/239), oportunidade em que requereu a revogação da prisão preventiva. O Parquet se manifestou contrariamente (fl. 243) e a decisão segregatória fora mantida (fls. 244/246). Por não ser o caso de absolvição sumária, também foi designada audiência de instrução e julgamento.

Na solenidade (fls. 300/307), iniciados os trabalhos, foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas em comum pelas partes, policiais militares Carlos Augusto e Thales Alberto, bem como daquelas arroladas exclusivamente pela defesa, Sergio Novaes, Jessica Mafra e Neide Barbosa, seguindo-se o interrogatório do acusado. Então, rumou o feito para os debates orais, em vista da inexistência de diligências complementares. Nos debates, a acusação protestou pela integral procedência da denúncia.

A defesa, por seu turno, e atendendo a pedido formulado, apresentou suas alegações finais por meio de memoriais, átimo em que requereu a absolvição do acusado, sob a égide da anemia de provas (fls. 312/324).

É o breve relato dos autos (artigo 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal manejada pelo Ministério Público com o fito de obter a condenação do acusado Daniel Bergues Ferreira Laves nas sanções do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

PRELIMINARMENTE:

Da ausência de justa causa:

Ab initio, alega a Defesa, em sua resposta escrita, inexistir justa causa a embasar a ação penal pública sub judice, em decorrência da inexistência de materialidade e autoria delitiva do inculcado. Todavia, na medida em que já recebida a denúncia, a questão se encontra superada, devendo ser solucionada quando da apreciação do mérito, não ensejando, assim, o atalhamento da lide.

Da inépcia da denúncia:

Ainda alega a defesa ser a denúncia inepta, em decorrência da forma genérica com que os fatos nela foram narrados, não havendo, assim, descrição clara acerca do fato delituoso sub judice. Sem razão, contudo. É que, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal:

"a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".

E, na hipótese dos autos, é o que se verifica, na medida em que declinou ela as circunstâncias de tempo e local em que os fatos supostamente ocorreram. Mais seria desnecessário. Preliminar que vai afastada.

NO MÉRITO:

A materialidade da narcotraficância encontra-se sobejamente evidenciada por intermédio do auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), do auto de constatação prévia de entorpecente (fls. 25) e, principalmente, do laudo toxicológico de fls 124/127, fls 167/169 e fls. 206/208, oportunidade em que concluíram os experts tratarem-se as substâncias apreendidas, totalizando, 395,7 gramas de Tetrahydrocannabinol, 17,1g de Cocaína, 6,4g de Tetrahydrocannabinol e 74 ml de Cloreto De Metileno/Doclorometano.

A autoria do acusado, da mesma forma, malgrado o louvável esforço da defesa, ressuma igualmente caracterizada pela prova testemunhal produzida.

Quando de seu interrogatório realizado em solo policial (fls. 08/09), o acusado o acusado usufruiu de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em Juízo, na essência, negou os fatos. Disse inicialmente já ter sido preso por roubo, viver em união estável com sua companheira, com quem tem um filho de 03 anos. Mora em São Paulo, onde administra um lava-rápido. Salientou ter vindo de São Paulo para Itanhaém para auxiliar seu sogro na edificação de um muro. No dia dos fatos, foi até o bar comprar uma trufa, onde, após descer do carro e conversar com todos, foi abordado pelos policiais militares, ao sair do banheiro. Não conhecia os policiais militares que o abordaram. Foi levado até sua casa, oportunidade em que, após ser revistado, nada de ilícito fora encontrado. Desconhece de onde surgiu a sacola apresentada no bar contendo os estupefacientes. Seu irmão, Douglas Ferreira Alvas, já fora preso no mesmo estabelecimento, por agressão, porém não sabe ao certo. Negou, derradeiramente, qualquer envolvimento com o tráfico.

Todavia, quando confrontada a versão externada pelo réu com as demais provas produzidas, desfalece ante sua fragilidade, evidenciando, sobremaneira, tratar-se de um subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal.

O Policial Militar Carlos Augusto, em seu depoimento prestado em solo policial (fls. 04/05) e em Juízo, alinhavou que na fatídica data estava em diligência com a viatura, acompanhando pelo também policial militar Thales, quando foram informados da suposta chegada de drogas em uma "biqueira", localizada na Rua Antônio Carlos Prado, bairro Jardim Coronel, Itanhaém. Por volta das 20 horas foram ao local e avistaram um indivíduo de pele parda, reconhecido mais tarde, por meio de consulta a seus documentos, como sendo Danielbergues Ferreira, portando uma sacola plástica preta, nas proximidades de um bar. Ao avistar a viatura, o indivíduo evadiu-se para dentro do bar, onde foi encontrado e detido, dentro do banheiro. Em revista pessoal nada ilícito foi encontrado, contudo, em sua sacola, fora localizada uma vultuosa quantidade de entorpecentes, entre eles 29 tiras de maconha, com peso bruto de 158 gramas, 105 envelopes plásticos com maconha, com peso bruto de 250 gramas, 93

pequenas pedras de crack, com peso bruto de 26 gramas, 40 pequenos potes transparentes contendo Skunk,, com peso bruto de 183 gramas, 32 pequenos potes vermelhos contendo Skunk, com peso bruto de 99 gramas, 3 frascos transparentes de Lançaperfume, com peso bruto de 110 gramas, não sendo possível aferir a quantidade líquida, uma agenda com anotações manuscritas, que aparentavam estar relacionadas com a contabilidade do tráfico de drogas, além da quantia de R\$ 152 (cento e cinquenta e dois reais). Entrevistado informalmente, o acusado disse trazer drogas da capital para abastecer a "biqueira" do bairro Jardim Coronel.

Sob o crivo do contraditório, ainda alinhavou que o acusado mencionou ter passado a ser o responsável por "abastecer" a biqueira, no lugar de seu irmão, preso por tráfico, no mesmo lugar, aproximadamente um ou dois meses dos fatos. O local em que se deu a abordagem, no bar, possui dois endereços, a depender do mapa a ser consultado. A denúncia recebida noticiava que a droga distribuída no bar vinha de São Paulo, e não que o réu a trazia de lá. O veículo não foi apreendido por não terem vislumbrado ser relacionado à atividade proscria.

Estes, em linhas gerais, foram os mesmos fatos articulados pelo Policial Militar Thales Alberto, em seu depoimento prestado em solo policial (fl. 06). Em juízo ainda reiterou ter avistado o momento em que o acusado trazia consigo a sacola preta, na qual encontrados os estupefacientes já elencados. Acrescentou que haviam mais pessoas presentes no bar em que se deu a prisão do acusado. A denúncia recebida não fornecia maiores detalhes, somente que a droga chegaria no bar e ali seria comercializada. Quando o inculcado avistou a viatura, em poder da sacola, rapidamente entrou no estabelecimento comercial e se deslocou até o banheiro, onde encontrado sozinho. Não levaram o proprietário do bar para a Delegacia porque, embora tivessem dele suspeitado inicialmente, não vislumbraram sua participação na narcotraficância. Não sabe dizer se haviam câmeras de monitoramento no bar em que se deu a prisão do réu.

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento da prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, relembre-se que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Outras provas foram produzidas.

A informante Jéssica, esposa do réu, esclareceu haver se surpreendido com a notícia de que seu marido fora preso, desconhecendo seu envolvido com a narcotraficância. Os policiais foram até sua residência por volta das 20h. Salientou que eles realizaram várias revistas no imóvel, todavia nada de ilícito encontraram. Foi proibida de ver Daniel, o qual se encontrava preso na viatura. Os milicianos lhe devolveram o carro do casal e o celular do inculcado. Já passou no bar em que se deu a prisão, mas não o frequenta; Daniel tampouco.

Sergio de Lisboa Novais, dono do estabelecimento em que se deram os fatos, ouvido como testemunha, afirmou que o o acusado, tão logo parou o carro e lhe pediu para ir ao banheiro, foi detido pelos policiais militares. O acusado não trazia consigo

qualquer sacola plástica. Não a viu posteriormente. Não sabe a razão pela qual o acusado foi preso no momento. O irmão do acusado também fora preso no mesmo bar, um mês antes, não sabendo esclarecer o motivo. Repetiu que, poucos segundos depois de Daniel haver ingressado no bar e lhe pedido para ir ao banheiro, os policiais apareceram. Ações policiais são uma constante no estabelecimento de sua propriedade. Acredita que quatro policiais participaram da ocorrência. A câmera de monitoramento que se encontrava instalada no bar foi apanhada, todavia não sabe dizer por quem. Nenhuma "biquera" se encontra situada nas imediações de seu bar. Perdeu o celular para onde eram direcionadas as imagens captadas pela câmera que estava instalada no bar.

Finalmente, Neide, testemunha arrolada pela defesa, disse ser vizinha de um imóvel de propriedade dos sogros do réu. Não há qualquer sistema de monitoramento em sua casa, pois trata-se de edificação simples.

Estas são as provas. Diferentemente do que pretende fazer crer a defesa, entendo assistir razão à acusação na imputação de tráfico realizada ao réu. É que a grande quantidade e variedade de drogas encontradas (total de 395,7 gramas de Tetrahydrocannabinol, 17,1g de Cocaína e 74 ml de Cloreto De Metileno/Doclorometano - fls 124/127, fls 167/169 e fls. 206/208) e as circunstâncias que envolvem o caso (o dinheiro apreendido juntamente das anotações, que na agenda, fazem referência ao tráfico, junto aos entorpecentes - fls. 128/130), transparecem a finalidade comercial do tipo penal.

Observe-se que os entorpecentes apreendidos já se encontravam em pequenas porções, adrede preparados para venda, que a abordagem fora realizada em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e realizada a pós atitude suspeita esboçada pelo acusado. Veja-se que os depoimentos prestados pelos policiais mostraram-se harmônicos, sendo, ainda, secundados pela apreensão de entorpecentes.

A versão esculpatória apresentada pelo acusado, aparentemente em harmonia com os depoimentos de Jéssica, Sérgio e Neide, por seu turno, não convence.

Neide, vizinha dos sogros do acusado, nada soube esclarecer a respeito dos fatos, porém, ao ser indagada, afastou a hipotética alegação de que câmeras de segurança instaladas nas imediações tivessem sido subtraídas. O testemunho de Jéssica, por seu turno, companheira do réu, ausente quando da prisão, em nada arrefeceu o conjunto probatório haurido. Finalmente, entendo que o depoimento de Sérgio, dono do bar em que se deram os fatos, deve ser recebido com amplas ressalvas por este Juízo, porquanto nítido seu propósito de favorecer o acusado.

A alegação de que a câmera de monitoramento instalada no interior do bar fora possivelmente furtada pelos milicianos, para o fim de se esquivarem de uma criminosa imputação falsamente realizada ao réu, soa no mínimo pueril. É sabido que o armazenamento das imagens se dá em dispositivo diverso ao da câmera e, ao ser confrontada a testemunha a este respeito, alegou, sintomaticamente, que perdera seu celular, local de armazenamento das imagens.

Não bastasse, indagado se conhecia o irmão do réu, Douglas Ferreira Alves, passou a tecer respostas evasivas, aludindo que teria ele sido preso por agressão, o que não confere com a realidade. O que se verifica, a bem dizer, por meio de rápida consulta aos autos 1500341-61.2021.8.26.0633, em trâmite na 2ª Vara local, é que fora ele preso em estado flagrancial no mesmo local, por tráfico, tal qual precisamente relatado pelos policiais militares ouvidos na audiência de instrução em julgamento.

Todo o contexto da situação flagrancial não deixa dúvidas, portanto, acerca da conduta ilícita cometida pelo acusado. De resto, não se pode imaginar razões que justifiquem a alegação de estarem os policiais a acusar um desconhecido da prática

de um delito, quando isso não ocorreu, unicamente para atender a algum sentimento íntimo sádico de culpar terceiros.

Diga-se de passagem, oportuno lembrar que:

“o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

E ainda:

“considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004).

Assim, dúvidas não pairam de que o réu encontra-se incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

DA PERDA DOS BENS:

Pela legislação em vigor, são três os tipos de bens que podem ser apreendidos: a) produtos do crime (artigo 60): vantagem direta obtida com a prática criminosa. Ex: o dinheiro recebido com a venda da droga; b) proveito auferido (artigo 60): é a vantagem indireta, conseguida a partir do produto, v.g., um carro comprado com a venda da droga; c) veículos, embarcações, aeronaves, maquinários, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática de crimes previstos na Lei (artigo 62).

Ademais, acentua a doutrina mais judiciosa que para a decretação da perda dos bens e valores apreendidos, mostra-se necessária a demonstração do nexó etiológico a os unir com o crime apurado.

Dito isso, tenho ser o caso de se decretar o perdimento do dinheiro (R\$ 152,00, fls 26/27) apreendido. Restando, pois, demonstrada a conduta criminosa, caberia ao réu indicar a origem do dinheiro, o que em nenhum momento se prestou a fazer.

DOSIMETRIA:

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado, deve ser considerada normal.

Não obstante reincidente (vide certidão das fls. 68/69, processo nº 0005723-30.2012.8.26.0050) – aspecto que será analisado na segunda etapa- o acusado não é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, não havendo condenação definitiva (fora dos casos de reincidência), tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer,

“(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado” (STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13.08.09).

Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social do acusado e sua personalidade não foram amealhados

elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios à espécie.

As circunstâncias devem ser consideradas gravosas, tendo em vista a vasta quantidade e diversidade das drogas (395,7 gramas de Tetrahydrocannabinol, 17,1g de Cocaína e 74 ml de Cloreto De Metileno/Doclorometano). Vale a consideração, também, que o montante de entorpecente apreendido se traduz no mercado ilícito em expressiva cifra. Nesse sentido:

"(...) na avaliação das circunstâncias legais para fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade de droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa" (STJ, Rel. José Arnaldo da Fonseca, HC 18940/RJ).

As consequências do crime foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias judiciais, aplico a pena-base ao réu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência, ex vi do art. 61, inc. I, do CP (certidão de fls. 68/69 do apenso, processo nº 0005723-30.2012.8.26.0050), agravo a pena em 1/6 (um sexto). Ausentes quaisquer atenuantes.

Ausentes quaisquer causas de aumento e de diminuição, inclusive a prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, considerando a expressiva quantia de entorpecente apreendida. É que tais circunstâncias revelam séria incursão do acusado na criminalidade, inculcando neste Juízo seja ela dedicada a atividades criminosas.

Não é preciso dizer muito para se compreender que a aquisição de tamanha quantidade de entorpecente não se dá com qualquer indivíduo, notadamente com o pequeno traficante. A perda da droga enseja inegável prejuízo, razão pela qual, no mundo do crime, exige-se responsabilidade de quem a transporta. Assim, se logrou o acusado assim agir, é porque está inserida na senda delitativa, não fazendo jus, portanto, à redução reclamada pela defesa. A este respeito, observo que:

"o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas" (STJ; HC 163495/SP; Rel. Min. Laurita Vaz; DJe 19/10/2011).

Inexistindo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06.

Considerando que Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), deve o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, não podendo fundamentar a fixação do regime inicialmente fechado unicamente em relação à hediondez do delito de tráfico de drogas.

A tese restou assim ementada:

“É inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.” (ARE 935.967 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15.03.2016)

Desse modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. Vale ressaltar que tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do §3º do art. 33, c.c art. 59 do Código Penal.

Na espécie, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo em vista a expressiva quantidade e a nocividade da droga apreendida (Tetrahydrocannabinol, Cocaína e Cloreto De Metileno/Doclorometano), ex vi do art. 33, §2º, 'b', e §3º do mesmo preceito. Não bastasse, como dito, trata-se de acusado reincidente.

A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito há de ser analisada sob o prisma do artigo 44 do Código Penal.

Conquanto expressa a vedação acerca da aplicação do instituto aos casos de tráfico, tal qual se depreende dos arts. 33, §4º, e artigo 44, ambos da Lei n. 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 97256, publicado em 16/12/2010, cujo relator foi o Min. Ayres Brito, em controle difuso de constitucionalidade, concedeu a segurança pretendida para:

“remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos', constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.” E isso por se entender que “o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material”.

Ademais, em 15/02/2012, o Senado Federal, valendo-se da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 52, inc. X, da Constituição Federal, editou a Resolução n. 5, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Ainda que a Resolução editada pelo Senado Federal tenha se limitado a suspender a restrição existente somente no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, forçosa é a extensão de sua leitura também para a redação dada ao art. 44 do mesmo diploma, quando veda o mesmo benefício. É que o precedente jurisprudencial que motivou a edição da Resolução referida entendeu por inconstitucional tanto a vedação contida no art. §4º do art. 33 como também a do art. 44, ambos da Lei n. 11.343/06.

Todavia, mesmo que assentadas tais premissas, as circunstâncias do caso indicam não ser recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou, ainda, a suspensão condicional de sua execução. Como já positivado, foram encontrados entorpecentes em grandes quantidades, a indicar merecer o agente maior reprovação na sua conduta.

Ademais, foram encontradas mais de uma espécie de entorpecente, o que revela nocividade em seu comportamento, não compatível com a branda possibilidade de concessão dos benefícios referidos (artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal).

DIANTE DO EXPOSTO:

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado, DANIEL BERGUES FERREIRA ALVES, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Deixo de condenar o réu em custas processuais, dada a hipossuficiência financeira denotada pelas provas amealhadas.

Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ante os fundamentos elencados na decisão de fls. 73/76, não reconheço ao acusado o direito de recorrer em liberdade, recomendando-se o ergástulo em que se encontra até o trânsito em julgado (art. 387, §1º, c/c art. 312, ambos do CPP).

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada à natureza difusa das vítimas.

Decreto a perda em favor de entidade beneficente cadastrada neste Juízo do dinheiro apreendido (vide fls. 26/27, R\$ 152,00).

Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB – Defensoria ao(s) procurador(es) nomeado(s). Expeça-se certidão com o trânsito em julgado.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

I) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(s) condenado(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal;

II) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento;

III) expeça-se guia de execução (ou de recolhimento), provisória ou definitiva, conforme o caso, para o devido encaminhamento do(s) condenado(s) ao estabelecimento prisional estabelecido nesta sentença;

IV) Transfira-se para entidade beneficente o dinheiro apreendido (fls. 26/27, R\$ 152,00);

V) Desde logo, não havendo interesse em recorrer, sai a parte acusada intimada para pagamento da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias. Sem prejuízo, extraia a serventia certidão de sentença a respeito da pena de multa imposta, abrindo-se vista ao Ministério Público.

Publique-se. I-se, devendo o réu o ser pessoalmente.

Comarca de Itanhaém, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA